

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5061109-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: IVALDO MOREIRA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SAÚDE - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA, COM ESFÍNCTER ARTIFICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - QUADRO FÁTICO INALTERADO - DECISÃO DE 1ª INSTANCIA MANTIDA POR AUSENCIA DE PERICULUM IN MORA - ART 300 DO CPC - PALIATIVO FORNECIDO POR MEIO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR, QUE DISPONIBILIZA GRATUITAMENTE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA -ALTERNATIVA PARA DIMINUIÇÃO DOS EFEITOS NEGATIVOS DA INCONTINÊNCIA, ENQUANTO AGUARDA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA - MODALIDADE RECURSAL QUE EXIGE, ALÉM DA DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO, A COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA, A QUAL NÃO RESTOU CARACTERIZADA NA HIPÓTESE, PELO QUE SE IMPÕE A MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGOU-LHES PROVIMENTO, devendo ser mantido o acórdão impugnado. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024.

5061109-18.2024.4.02.5101

510014561427 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5061109-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA
RECORRENTE: IVALDO MOREIRA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, no qual se alega omissão do julgado proferido por esta 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro.

Conheço do recurso interposto, eis que tempestivo.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Os embargos declaratórios constituem modalidade de recurso com alcance bem definido, cabíveis apenas em caso de **obscuridade**, **contradição** ou **omissão** do provimento judicial atacado, nos termos do artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil; e, no

âmbito dos Juizados Especiais, a teor do que dispõem os artigos 48 a 50 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1º da Lei nº 10.259/01.

Preliminarmente, destaca-se que o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, **sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes**, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial. Inteligência do art. 489, § 1º, IV, do CPC:

Art. 489. (...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

O embargante sustenta que "*fundamentos jurídicos que deixaram de ser enfrentados por esta Colenda Turma, quais sejam: 1) a norma do §2º do artigo 2º da Lei 12.732/12, que dispensa tratamento privilegiado e gratuito aos pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna; 2) as normas hospedadas na Lei nº 14.238/21, que institui o Estatuto da Pessoa com Câncer e prevê ser dever do poder público assegurar à pessoa com câncer, prioritariamente, a plena efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde, garantindo o tratamento adequado da dor, atendimento multidisciplinar e cuidados paliativos.*".

A cognição do recurso de medida cautelar é restrita, ou seja, a tutela para ser deferida nesta espécie recursal depende da demonstração tanto da probabilidade do direito quanto do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O caso não se refere a manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna ou ausência de *plena efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde, garantindo o tratamento adequado da dor, atendimento multidisciplinar e cuidados paliativos*. A realização da cirurgia pretendida pretende **cessar a incontinência urinária**, com a introdução de esfíncter artificial.

O autor foi submetido a cirurgia de prostatectomia radical devido a neoplasia de próstata em **03/02/2021**, conforme fl.12 do evento 1, ANEXO2 dos autos originários. Em informações do Hospital Federal do Andaraí, foi dito que o autor encontra-se **aguardando cirurgia** para correção de incontinência urinária com esfíncter. Apresentou **documento médico não datado** (fl. 13 do evento 1, ANEXO2), **de quando possuía 65 anos (atualmente está com 66) solicitando risco cirúrgico** para esfíncter artificial.

Em informações do Hospital Federal do Andaraí (fl. 17 do evento 1, ANEXO2), **datada de 06/05/2024, consta que o autor encontra-se aguardando cirurgia** para correção de incontinência urinária com esfíncter artificial, **sendo o primeiro da fila para este procedimento**. O referido nosocômio ainda informou que, **apesar de ter solicitado os esfíncteres artificiais necessários, ainda não os recebeu do Ministério da Saúde** e que convive com outras dificuldades de abastecimento e paralisações.

Pelas informações prestadas pelo Hospital Federal do Andaraí e pela Câmara de Resolução de Litígios em Saúde, verifica-se que o procedimento cirúrgico requerido é fornecido pelo SUS. Entretanto, apesar de o autor ser o **primeiro da fila para sua realização, ainda não obteve o procedimento por ausência de material necessário** no referido nosocômio.

O unico obice, portanto, para a realização do procedimento é o fornecimento pelo Ministerio da Saude, órgão federal representado pela União, do material essencial ao procedimento, sem o qual não há como realizar a cirurgia.

Dado que o pedido para realização do risco cirúrgico foi efetuado quando ele ainda tinha 65 anos, considerando sua data de aniversário, pode-se concluir que está a espera da referida cirurgia **há pelo menos 3 meses**, sem desconsiderar que a questão provavelmente surgiu a partir da cirurgia de retirada da próstata realizada em 2021. Entretanto, apesar de todos os evidentes e elevados dissabores ocasionados pela incontinência urinária, não há como caracterizar urgência por ausência de risco de morte do autor. Mais do que isso: a cirurgia não é realizada, não por existencia de outros pacientes em fila, mas simplesmente porque o Ministerio da saude não fornece o que caberia a ele fornecer.

Neste ponto, a adesão ao programa de fraldas geriátricas pelo Programa Farmácia Popular do Brasil parece ser a solução paliativa como posto na liminar ante a inercia do Executivo.

Nesses termos, diante da ausencia de urgência, em que pese o flagrante e revoltante descaso do Ministerio da Saude, existe alternativa paliativa para diminuição dos efeitos negativos da incontinência que são, neste primeiro momento, o que resta ao autor ante, repita-se, o descaso e indiferença do Poder Executivo.

Portanto, apesar de demonstrada a probabilidade do direito perseguido, resta ausente a demonstração de qualquer urgência, dada a ausência de perigo à vida ou à saúde do autor, requisito indispensável para que fosse deferida a tutela recursal vindicada, havendo alternativa terapêutica paliativa em disponível ao autor até que venha a realizar a cirurgia.

A Turma Recursal apreciou a legislação de regência da forma que, sob sua ótica, mais se coaduna com a hipótese, ainda que não seja esta a que satisfaça a parte embargante. Deste modo, descabe, na espécie, o requerimento de manifestação expressa sobre supostas ofensas à lei ou à Constituição Federal, a título de prequestionamento, pois a fundamentação adotada é suficiente para a solução do caso concreto, tal como preceitua o artigo 93, IX, da Carta Constitucional.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em Questão de Ordem suscitada pelo Ministro Gilmar Mendes no AI 791292 QO-RG, julgada em 23.06.2010 (DJe-149 - 12.08.2010), após reconhecer a repercussão geral do tema, reafirmou a jurisprudência no sentido de que **“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”**. Precedentes citados: MS 26.163, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.9.2008; RE 418.416, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19.12.2006.

Registre-se que o recurso interposto, ainda que com o fim de prequestionamento, deve observância ao artigo 1.022 do CPC (artigo 535 do antigo CPC), **o que não ocorreu na hipótese**. Nesse sentido: EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 2/10/2006; EDcl no AgRg no REsp 932.578/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; EDcl no AgRg no REsp 932.578/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009.

O que se verifica, no caso concreto, é a pretensão de promover a rediscussão da matéria, com o intuito de fazer prevalecer a tese jurídica invocada pelo(a) recorrente. Nesse contexto, os presentes embargos não se prestam ao fim pretendido pela parte embargante, que poderá, no entanto, valer-se da via recursal adequada.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores. No âmbito do STF, podemos citar o **ARE 831892 AgR-ED** (Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 20-04-2015 PUBLIC 22-04-2015) e o **RE 599271 AgR-AgR-ED** (Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 21-09-2015 PUBLIC 22-09-2015). No STJ, destaco o seguinte precedente: **AgRg no AREsp 548.441/RJ** (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014).

Destaque-se, por fim, o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, hipótese na qual se aplica o seguinte dispositivo do NCPC:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO**, devendo ser mantido o acórdão impugnado. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.